

0024664-52.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... denunciado pela prática do delito de Tráfico de Drogas e Condutas Afins.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0024664-52.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0024664-52.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2466/2017 -

10º Distrito Policial - Penha, 425/2017 - 10º Distrito Policial - Penha

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILMAR MARCELINO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

GILMAR MARCELINO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 28 de março de 2017, por volta das 13h, na Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, s/n, no interior da "Comunidade do Postinho", Parque do Carmo, nesta cidade de São Paulo, juntamente com o adolescente Pedro Henrique Mendes Silva Valentino, agindo em concurso de agentes, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, guardava, para fins de tráfico, 31 (trinta e um) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 9,7g (nove gramas e sete decigramas) e 17 (dezessete) invólucros contendo Cannabissativa L, vulgo maconha, com peso líquido de 40,7g (quarenta gramas e sete decigramas).

Segundo a exordial, o denunciado decidiu levar a cabo o comércio espúrio de drogas. Para tanto, dirigiu-se ao local supramencionado, conhecido como ponto de tráfico, em posse das substâncias descritas, individualmente embaladas e prontas para entrega no varejo, fazendo-o na companhia do adolescente Pedro Henrique Mendes Silva Valentino. Com efeito, GILMAR permanecia na entrada da "biqueira", atuando como "olheiro", realizando a segurança do local e garantindo o sucesso da

empreitada criminosa. Enquanto isso, o adolescente Pedro, mais ao fundo, efetuava a entrega do entorpecente apenas aos usuários cujo ingresso era autorizado pelo denunciado. Ocorre que policiais civis se dirigiram ao logradouro para verificar a informação de que se tratava de ponto de tráfico. Lá chegando, avistaram o denunciado e o adolescente em local conhecido como "biqueira" e decidiram se aproximar, identificando-se como usuários. Então, os agentes públicos foram recebidos por GILMAR, o qual confirmou a venda de cocaína no local e, após breve revista pessoal realizada nos supostos compradores, autorizou a sua passagem para que adquirissem os entorpecentes com o adolescente Pedro. O referido adolescente retirou um invólucro de cocaína da "pochete" que trazia consigo, afirmando que custava R\$ 10,00 (dez reais). Neste momento, os policiais se identificaram e detiveram GILMAR e seu comparsa. Em revista pessoal ao adolescente Pedro, os agentes localizaram, no interior da "pochete", o restante das drogas apreendidas, além da quantia de R\$ 20,00 (vinte reais), em cédulas fracionadas, proveniente da venda de drogas. A quantidade, diversidade e forma de embalagem das drogas apreendidas (invólucros prontos para a entrega a terceiros), aliadas às circunstâncias da prisão e à apreensão de dinheiro trocado evidenciam, com a segurança necessária, que se destinavam ao tráfico. Na denúncia foram arroladas as testemunhas Dirceu Alves de Souza (PC) e ADRIANA RIBEIRO (PC).

Recebida a denúncia em 09/05/2017 às fls. 104/105.

O réu foi citado (fls. 146).

Resposta à acusação oferecida pela Defensoria Pública a fls. 149. Nessa oportunidade, foram arroladas as mesmas testemunhas da acusação.

Afastada a possibilidade de absolvição sumária e mantido o recebimento da denúncia, foi designada data para audiência de instrução e julgamento (fls. 152/153).

Em audiência realizada em 23 de março de 2022, foi decretada a revelia do réu e ouvida a testemunha Adriana Ribeiro. Nessa oportunidade, o Ministério Público insistiu na oitiva da testemunha Dirceu Alves De Souza, sendo, em razão disso, designada audiência em continuação.

Laudo pericial da pochete apreendida juntado a fls. 109/113 e 185/187.

Laudo pericial químico-toxicológico a fls. 188/190 e 191/193.

A testemunha Dirceu Alves de Souza foi devidamente requisitada para audiência (fls. 183/184).

Certidões criminais do acusado juntada a fls. 178/180, sendo o réu reincidente.

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas, bem como o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público pugnou pela improcedência da ação penal no mesmo sentido foi o pleito da defesa

É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática do delito de Tráfico de Drogas e Condutas Afins.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

A existência do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 2), boletim de ocorrência (fls. 23/26), auto de exibição/apreensão/avaliação (fls. 27/28), termo de declarações e interrogatório (fls. 6,9), laudo pericial (fls. 109/113) e, sobretudo, pela prova oral colhida.

O mesmo não é possível dizer da autoria.

Na delegacia, o réu GILMAR MARCELINO DOS SANTOS disse que se encontrava no local para comprar drogas, não participando do tráfico de entorpecentes.

Em juízo, o réu GILMAR MARCELINO DOS SANTOS ficou em silêncio.

A testemunha Dirceu Alves de Souza (PC) contou que leu o B0 e que fizeram vários outros flagrantes no local, que não se lembra do rosto do réu, mas o modus operandi era o mesmo que costumavam utilizar. Leu o B0 e tinha um menor envolvido. Não se recorda quem pegou quem. Só está relatando o que leu no B0.

A testemunha Adriana Ribeiro (Policia Civil) afirmou que não se recorda da dinâmica da ocorrência, embora tenha relido sua oitiva. Na época, trabalhava no 10º DP. Trabalhou com Dirceu Alves de Sousa, embora não se recorde dele. Confirma assinatura presentes nos autos às fls. 5.

Analisando o conjunto probatório, conclui-se que não há uma única prova, produzida em juízo, no sentido de que o acusado tenha sido um dos autores do grave crime cometido.

Tal circunstância, desacompanhada de provas judicializadas da autoria, não permite que se chegue a um decreto condenatório.

Tal proteção ao contraditório é de tanta importância que na reforma legislativa de 2008, foi incluída expressamente essa previsão no artigo 155 do Código de Processo Penal que diz: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EMBASADO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. EXPRESSA DESCONFORMIDADE COM A REGRA PREVISTA NO ARTIGO 155 DO CPP. OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em respeito à garantia constitucional do devido processo legal,

a legitimidade do poder-dever do Estado aplicar a sanção prevista em lei ao acusado da prática de determinada infração penal deve ser exercida por meio da ação penal, no seio da qual ser-lhe-á assegurada a ampla defesa e o contraditório. 2. Visando afastar eventuais arbitrariedades, a doutrina e a jurisprudência pátrias já repudiavam a condenação baseada exclusivamente em elementos de prova colhidos no inquérito policial. 3. Tal vedação foi abarcada pelo legislador ordinário com a alteração da redação do artigo 155 do Código de Processo Penal, por meio da Lei n. 11.690/2008, o qual prevê a proibição da condenação fundada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. 4. Constatado que o Tribunal de origem utilizou-se unicamente de elementos informativos colhidos no inquérito policial para embasar o édito condenatório em desfavor do paciente, imperioso o reconhecimento da ofensa ao aludido dispositivo do Estatuto Processual Penal, já em vigor na data da prolação do acórdão objurgado, bem como à garantia constitucional ao devido processo legal. 5. Ordem concedida para cassar o acórdão condenatório apenas com relação ao paciente, restabelecendo-se a sentença absolutória proferida pelo magistrado singular, com a determinação de expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso. (STJ - HC: 123295 MT 2008/0272631-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 29/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2009)

A unilateralidade das investigações desenvolvidas pela polícia judiciária na fase preliminar da persecução penal e o caráter inquisitivo que assinala a atuação da autoridade policial não autorizam, sob pena de grave ofensa à garantia constitucional do contraditório e da plenitude de defesa, a formulação de decisão condenatória cujo único suporte seja a prova, não reproduzida em juízo, consubstanciada nas peças do inquérito, eis que é somente em juízo que se torna plenamente exigível o dever de observância ao postulado da bilateralidade de da instrução criminal contraditória.

A inaplicabilidade da garantia do contraditório ao procedimento de investigação policial tem sido reconhecida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência dos tribunais, cujo magistério tem acentuado que a garantia da ampla defesa traduz elemento essencial e exclusivo da persecução penal em juízo.

Nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada

na denúncia.

EMENTA: I. Habeas corpus: falta de justa causa: inteligência. 1. A previsão legal de cabimento de habeas corpus quando não houver "justa causa" para a coação alcança tanto a instauração de processo penal, quanto, com maior razão, a condenação, sob pena de contrariar a Constituição. 2. Padece de falta de justa causa a condenação que se funde exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial. II. Garantia do contraditório: inteligência. Ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação. STF, RE 287658 / MG - MINAS GERAIS Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE Julgamento: 16/09/2003

Em suma, da prova oral produzida em juízo não se extraem elementos suficientes para um decreto condenatório.

Desta feita, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que, no processo criminal, o decreto condenatório exige certeza absoluta, baseada em dados objetivos indiscutíveis, que evidenciam, de forma indubitosa, o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade de serem os acusados os autores do fato criminoso.

Em razão disso, já se decidiu: "A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível criminoso é condenar um possível inocente". (TJSP - AC 142.227-3 - Rel. Nelson Fonseca - JTJ 170/315).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO o réu GILMAR MARCELINO DOS SANTOS, qualificado nos autos, das sanções rtigo 33 "caput", da Lei 11.343/06 por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe.

Custas não são devidas.

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA